

0012826-73.2015.8.26.0506

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 409/2015 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cesar Moraes Zemantauskas

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

CÉSAR MORAIS ZEMANTAUSKAS está sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0012826-73.2015.8.26.0506 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

0012826-73.2015.8.26.0506

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 409/2015 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cesar Moraes Zemantauskas

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

CÉSAR MORAIS ZEMANTAUSKAS está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, possuía e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico ilícito, a quantidade de 272,313 gramas de cocaína, acondicionadas em 1038 microtubos de plástico do tipo eppendorfs, 53,853 gramas de cocaína, na forma de 200 pedras de crack e, por fim, 252,263 gramas de maconha, na forma de 38 porções, bem como, após receber de maneira escusa, mantinha sob sua guarda acessório de arma de fogo, de uso permitido, consistente em um carregador utilizado em pistola do calibre 7,65mm, com capacidade para doze cartuchos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O processo foi suspenso nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal em 22/08/2016, conforme fls. 116.

Em 24/01/2020 foi revogada a suspensão do processo e determinado o prosseguimento do feito (fls. 167).

Notificado (fls. 162), o réu ofereceu defesa prévia (fls. 176/179) e a denúncia foi recebida (fls. 180/181).

Durante a instrução, inquiriram-se quatro testemunhas e interrogou-se o réu.

Ao final, as partes debateram, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 no máximo legal, a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está provada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), pelas fotografias (fls. 08/10), pelo laudo de exame químico-toxicológicos (fls. 17/19), pelo laudo pericial do acessório de arma de fogo (fls. 35/37), pelo laudo do objeto apreendido relacionado ao crime (fls. 39/41) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria do réu também é certa.

O réu não foi interrogado na fase de investigações.

Henrique César P. Campanér, policial civil, ouvido em juízo, declarou que:

Não participou das diligências, que foram realizadas pela D.I.G., equipe do policial Cristino. Tomou conhecimento dos fatos na D.I.S.E através de uma ordem de serviço para localizar o réu, que não foi localizado na época, pois havia se mudado do local. O indiciamento do réu foi feito de forma indireta. Não conhecia o acusado. Embora não tenha participado da diligência não ficou qualquer dúvida de que o réu residia no local onde a droga foi encontrada, uma vez que no local foram localizados documentos dele, bem como a sogra confirmou que ele resida no local.

Cristino de Alcântara Tavares, policial civil, ouvido em juízo, relatou que:

No dia do ocorrido, após ter recebido denúncia de que no local dos fatos havia drogas e arma, para lá se dirigiram e, chegando, foram atendidos pela sogra do acusado, a qual anuiu com a entrada do declarante, sendo que no local foram localizadas porções de drogas diversas, já separadas, bem como carregador de arma de fogo e o documento em nome de Cesar Moraes Zemantauskas, tendo a sogra dele confirmado que ele ali residia. Durante a realização da diligência ele não se encontrava em casa. Não se lembra de maiores detalhes, tendo em vista o tempo decorrido. Não ficou dúvida quanto a quem residia no local.

Anderson Nunes da Silva, também ouvido em juízo, declarou que:

O réu morou alguns meses próximo à sua residência. Acredita que nessa época ele já

havia saído de lá, pois havia discutido com a esposa. O acusado é uma boa pessoa, trabalhador. A esposa do réu se chamava Gabriela. Ele tem filhos. Residia na esquina da sua casa, no bairro Jardim Bela Vista, Rua Jorge de Lima. Não sabe dizer se ele tinha parentes que residissem próximos do local.

José Luis Garcia, ouvido em juízo, declarou que:

O réu é seu empregado. Nunca teve problemas com ele. Acredita que ele tenha sido registrado em 2015.

César Moraes Zemantauskas, interrogado em juízo, alegou que:

Não teve ciência desses fatos. Ficou sabendo apenas no final de 2019 quando foi fazer um documento. Não residia mais no local fazia dois meses, já havia se separado da sua esposa. Morou no local por cerca de três meses com a sua esposa. Residiu no local no final de 2014 e desocupou o imóvel no início de 2015. Morava no imóvel ele e a sua esposa e o filho pequeno. Sua sogra não frequentava a residência. Ninguém estava residindo no local na data dos fatos. Sua sogra residia próximo ao local. Elas nunca se envolveram com o tráfico, são boas pessoas. Não conhece os investigadores de polícia inquiridos. A casa era alugada. A proprietária residia próximo do local. Acredita que tenha feito a locação em seu nome. Não possuía um bom relacionamento com a sua ex-sogra.

Pois bem.

Em seu interrogatório, o réu negou a posse das drogas e do acessório de arma de fogo apreendidos.

Sua negativa, porém, não prospera por estar isolada das provas dos autos, que evidenciam que as drogas apreendidas estavam sob sua guarda.

A autoria do réu está amplamente corroborada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Com efeito, as testemunhas de acusação Henrique e Cristino disseram que a própria sogra do réu confirmou que ele e a esposa residiam no imóvel.

As testemunhas de defesa, Anderson e José Luis, ouvidas em juízo, nada souberam informar sobre os fatos.

A residência não estava devassada, com portas ou portões arrombados, por exemplo, nem em estado de abandono. Os investigadores apuraram no local que o réu ali residia.

O próprio réu não negou que residisse no local, apenas alegou que se teria mudado dali pouco antes da diligência policial que resultou na apreensão das drogas.

Nenhum elemento de convicção nos autos permite supor que terceiros tenham inserido as drogas na sua residência.

Não bastasse, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 06, documentos pessoais do acusado também foram encontrados no imóvel, na mesma oportunidade em que se apreenderam as drogas.

No mais, a significativa quantidade e a variedade de entorpecentes encontrados, a maneira como estavam acondicionados, bem como a presença de petrechos comumente utilizados no embalo, evidenciam que as drogas se destinavam ao tráfico.

Portanto, inevitável o reconhecimento da autoria do réu, uma vez que ficou bem demonstrado nos autos que ele residia no local e que as drogas estavam sob sua custódia.

Já em relação ao delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, no presente caso concreto, é imperativo.

Em diligências pela residência do acusado, os investigadores não localizaram nenhuma arma de fogo na posse do acusado, apenas um carregador vazio, desvinculado das respectivas munições e até mesmo da respectiva arma (fls. 39/41).

Assim, é imperioso reconhecer a atipicidade material do fato por ausência de lesividade da conduta.

A ação do réu de manter sob sua guarda acessório (carregador) caracteriza formalmente o delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, pois o fazia, no interior da sua residência, sem autorização legal ou regulamentar.

Entretanto, conforme ressabido, para a caracterização do crime, em sentido material, é imprescindível que a conduta efetivamente lese ou, ao menos, gere perigo real e concreto de lesão a direito de outrem.

Embora haja divergência doutrinária em relação aos chamados crimes de "perigo

abstrato", o fato é que a aplicação indiscriminada e descuidada das normas penais que os definem pode violar, como no presente caso, o princípio da lesividade ou da alteridade e, conseqüentemente, configurar agressão à liberdade individual, direito inerente a todo ser humano e positivado pela Constituição da República em seu art. 5º.

Em suma, não se pode considerar crime, em sentido material, qualquer conduta que não constitua lesão, ou perigo de lesão concretamente demonstrado, a direito de outra pessoa (princípio da alteridade).

Só existe crime, em sentido material, se a conduta constitui lesão efetiva ou, ao menos, coloca em perigo real o direito de outrem.

Ou seja, a previsão formal e abstrata de determinada conduta como crime não exige o julgador de verificar, em cada caso concreto, se de fato houve lesão ou perigo real de lesão ao direito de outrem em decorrência da ação do acusado.

Em sua crítica à teoria da concepção imaculada do estado de Nozick, Murray Rothbard enuncia a seguinte máxima, que, uma vez aplicada à própria existência e manutenção do estado, logicamente, tem aplicação no Direito Penal, que representa a intervenção estatal mais drástica na liberdade individual:

"Ninguém tem o direito de coagir qualquer pessoa que não esteja diretamente empenhada em um ato evidente de agressão contra direitos. Permitir um mínimo afrouxamento deste critério, para incluir coerção contra "riscos" remotos, é sancionar agressões inadmissíveis contra os direitos dos outros. Além disso, qualquer afrouxamento deste critério é um passaporte para o despotismo ilimitado." (in "A Ética da Liberdade", Instituto Ludwig Von Mises Brasil, 2ª ed., p. 316)

Retornando ao caso concreto em análise, não há nos autos prova de que o acessório que o acusado mantinha sob sua guarda estaria vinculado a alguma arma de fogo, do respectivo calibre, que também estivesse sob sua guarda. Pelo contrário, como visto, nenhuma arma foi apreendida na ocasião dos fatos sob responsabilidade do acusado.

De todo modo, a mera guarda do carregador, no interior da residência, em si mesma, não caracteriza lesão ou perigo real de lesão ao direito alheio.

Em suma, dadas as peculiaridades do caso concreto em análise, não se identifica na conduta do acusado a potencialidade lesiva exigida para a caracterização de crime, em sua acepção material.

Ou seja, não há a chamada tipicidade material, razão pela qual a absolvição se impõe, já que, nesse caso, o fato não constitui crime.

Desse modo, incorreu o acusado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo, portanto, ao cálculo das penas.

De início, deve-se ressaltar que não é correto, aliás, é absolutamente divorciado da boa técnica jurídica, o procedimento consistente em fazer incidir frações sobre a pena mínima a cada circunstância judicial desfavorável.

Primeiro, porque pena-base não se aumenta nem se diminui; fixa-se, com observância dos parâmetros estabelecidos pelo art. 59 do CP (art. 68 do CP).

Justamente por isso sua denominação é "pena-base", porque é sobre ela que incidirão eventuais frações nas duas fases subseqüentes da dosimetria.

Ora, se não há ainda pena-base fixada, não se cogita de "aumento" ou "redução" e, conseqüentemente, da incidência de frações.

Segundo, porque, quando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas é consideravelmente amplo, como no caso em apreço (5 a 15 anos de reclusão), mesmo que todas as 8 circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP fossem desfavoráveis ao réu, a aplicação de tal procedimento errôneo, ou seja, a incidência de 1/6 (fração comumente aplicada) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável - 8/6 (oito sextos) sobre 5 anos - jamais permitiria que a pena atingisse o máximo cominado.

Ou seja, a cominação legal de pena máxima não teria qualquer função, interpretação que obviamente deve ser descartada, por absurda, já que a lei não pode conter termos inúteis.

Feitas tais observações, na primeira fase de dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, destaca-se a expressiva quantidade das drogas apreendidas (272,313 gramas de cocaína, acondicionados em 1038 microtubos de plástico do tipo

ependorfs, 58,853 gramas de cocaína, na forma de 200 pedras de crack e 252,263 gramas de maconha, na forma de 38 porções). Trata-se, pois, de conduta relacionada ao tráfico em larga escala, porquanto capaz de atingir milhares de usuários, como visto. Além disso, também nos termos do dispositivo legal citado, ressalta-se a natureza de parte dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack), cujo poder de destruição da saúde física e mental é devastador. Tais circunstâncias evidenciam, de outro lado, o elevado grau de culpabilidade do réu no delito, na medida em que revelam o intenso dolo com que agiu, elevando sobremaneira o juízo de censurabilidade de sua conduta. Assim, obedecendo aos parâmetros dos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, está presente a agravante decorrente da reincidência específica do réu, conforme certidão de distribuições criminais (autos n. 0001095-51.2013.8.26.0506 – fls. 236). Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando, nesta fase, em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Por fim, na terceira e última fase, não há causas de aumento ou redução, pelo que fica definitiva a pena acima fixada, observando-se ser incabível o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente específico, como visto.

Fica definitiva, portanto, a pena acima calculada.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, por ausência de maior conhecimento da capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, nos termos do art. 33, §2º, a, do CP.

Entretanto, o réu poderá recorrer em liberdade, pois assim respondeu ao presente processo e não sobrevieram razões que justificassem a decretação de sua prisão preventiva.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva para:

- a) condenar o réu CÉSAR MORAIS ZEMANTAUSKAS, qualificado a fls. 64, às penas de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, de valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06;
- b) absolver o réu CÉSAR MORAIS ZEMANTAUSKAS, qualificado a fls. 64, da acusação de ter praticado, nas circunstâncias descritas na denúncia, o crime definido no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, façam-se as comunicações de praxe e diligencie-se pela execução das penas.

Conforme requerido na defesa prévia a fls. 178, fica concedida a assistência judiciária gratuita, ficando o réu dispensado do pagamento das custas.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 28 de janeiro de 2022.

Giovani Augusto Serra Azul Guimarães
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA